

1501460-62.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade do delito.

A Defesa arguiu ilicitude da ação dos guardas civis. Em caso de condenação por tráfico, requereu o reconhecimento do privilégio.

É o relatório.

Decido.

Afasto a tese defensiva de que houve ilegalidade na ação dos guardas civis e, conseqüentemente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501460-62.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2257985/2021 - 02º D.P.

PIRACICABA, 20389408 - 02º D.P. PIRACICABA, 3647/21/518 - 02º D.P. PIRACICABA, 2257985 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS PAULO DOS ANJOS SANTOS

Réu Preso

Contr. nº 2021/001023

Aos 12 de janeiro de 2022, às 13:30 horas, por meio de audiência virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr. Sandra Regina Ferreira da Costa foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu DOUGLAS PAULO DOS ANJOS SANTOS (preso Pen. Piracicaba). Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: GC Paulo Cesar Cavalcante e GC CESAR EDUARDO BOTTENE.

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

Pela M.M Juíza de Direito foi explicado que, diante da restrição de acesso ao prédio do Tribunal de Justiça, em razão da pandemia do COVID-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e orientação do Comunicado CG nº 284/2020, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft.

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala,

inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (GCs César e Paulo) em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: ALEGAÇÕES FINAIS, GRAVADAS EM ÁUDIO E VÍDEO.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). DOUGLAS PAULO DOS ANJOS SANTOS vem processado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme os fatos narrados na inicial acusatória. Após o recebimento da denúncia, a ação penal teve seu regular trâmite e a instrução foi encerrada na presente audiência. Em suas alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

Ocorre, contudo, que a pretensão ministerial não encontra guarida, devendo a ação penal ser julgada improcedente Excelência, inicialmente a Defesa requer seja reconhecida a ilicitude de toda a prova que embasou a presente ação penal. Com efeito, no caso em tela, houve indevida atuação dos guardas municipais, que praticaram atos para os quais não detém competência. Ora, como se sabe, a teor do art. 144, § 8º, da CF, não é tarefa da GCM o policiamento ostensivo, que foi o que aconteceu no presente caso em que durante patrulhamento os agentes municipais acabaram suspeitando da ação do réu, motivo pelo qual resolveram abordá-los, só então apurando o que realmente acontecia. Isso, aliás, foi declarado pelos guardas municipais que disseram que abordaram o acusado por conta de um comportamento suspeito. Posteriormente, é verdade, houve a localização da droga. Mas isso não torna válido o desvio de função dos agentes municipais. A situação, outrossim, não encontra amparo na primeira parte do art. 301, do CPP, que permite que qualquer do povo efetue a prisão em flagrante. O flagrante na verdade só aconteceu porque muito antes os guardas civis municipais, por conta própria, ampliaram suas atribuições, realizando policiamento ostensivo e investigando possíveis infrações penais, o que é ilegal e inconstitucional. Não há, pois, como dizer que nessa situação, qualquer do povo poderia agir. Afinal, não se vê qualquer do povo revistando terceiros que reputam suspeitos. Nem mesmo fazendo entrevistas. Nessa linha, não há como não considerar que a busca pessoal efetuada é verdadeiro ato investigativo, para a qual os integrantes da GCM, reitero-se, não tem atribuição. A propósito, sobre a busca pessoal, Gustavo Henrique Badaró assim ensina: "Há divergência sobre quem teria atribuição para realizar tais buscas. Não se discute sobre a possibilidade de a autoridade policial, federal ou civil, e de seus agentes realiza-las, até mesmo porque constitucionalmente lhes incumbe a atividade de polícia judiciária (CR, art. 144, § 1º, IV, e § 4º). Por sua vez, no caso de policiais militares, a matéria é controvertida. A polícia militar, embora tenha por finalidade a prevenção ao cometimento de crimes, também tem o escopo de atividade de imediata repressão aos delitos. Assim, não se pode conceber que, na atividade de policiamento preventivo e de imediata repressão a crimes que estejam ou acabaram de ser cometidos, o policial militar não possa, desde que respeitados os requisitos legais, realizar uma busca pessoal, havendo fundada suspeita de que alguém porta um arma ou certa quantidade de droga. Por outro lado, há consenso no sentido de que os guardas municipais não podem realizar buscas pessoais. Por expressa previsão constitucional, cabem-lhes apenas a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo atribuída nenhuma função de prevenção ou investigação de crimes". (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 8ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 588). E no mesmo sentido assim decidiu recentemente o C. Superior

Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Considera-se ilícita a revista pessoal executada por guardas municipais, sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Tendo a busca pessoal ocorrido sem estar o paciente em situação de flagrância, após dias da prática do crime, por guardas municipais que o abordaram sem fundadas razões, apenas por reconhecer sua foto em postagens na rede social comunitária, realizando verdadeira atividade de investigação, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova. 3. Habeas corpus concedido para declarar ilegal a apreensão e, consequentemente, absolver o paciente, nos termos do art. 386, II, do CPP". (STJ - HC 561.329/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020). Enfim, sendo ilícita a ação que originou a apreensão do entorpecente e a consequente prisão do réu, forçoso reconhecer que as demais provas estão contaminadas por tal ilegalidade. Assim, devem ser desconsideradas, de modo que, na falta de provas válidas, deve o acusado ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Caso, no entanto, superada a questão preliminar levantada, a absolvição do acusado pela prática do tráfico, no mérito, é medida que se impõe. Isso porque o que o incrimina é apenas o que foi dito pelos guardas civis municipais, que não podem ser consideradas testemunhas totalmente isentas, tendo em vista que participaram diretamente da prisão do acusado. Sobre isso ainda deve ser considerada a possibilidade de terem atuado de forma contrária às suas atribuições, como já apontado. Assim, é evidente que os servidores municipais tem interesse em justificar seus atos, o que retira o valor probatório de seus testemunhos. Dessa forma, sendo precária a prova produzida, requer-se a absolvição do acusado em razão da falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta do réu para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. Todavia, caso o entendimento de Vossa Excelência seja pela condenação, é preciso considerar que há qualquer circunstância que autorize a exasperação da pena. Houve apreensão de pequena quantidade entorpecente, a qual não justifica apenamento mais severo no cálculo da pena-base. Na segunda etapa, requer-se o reconhecimento da atenuante da confissão, pois o réu admitiu o crime na fase policial e novamente em juízo. Com o reconhecimento de tal atenuante, fica neutralizado o efeito da reincidência. Já na terceira fase, mostra-se possível a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Isso porque não há prova de que o réu integre associação ou organização criminosa. Além disso, a não incidência do redutor apenas em razão da reincidência do réu se mostraria desproporcional no caso concreto, sobretudo diante de suas condições pessoais e, ainda, da ínfima quantidade de entorpecente apreendida - 3,3 gramas de crack, 1,9 grama de cocaína em pó e 19,8 gramas de maconha. Ademais, a negativa do redutor tão somente em função da reincidência também caracteriza bis in idem, já que referida circunstância é considerada para aumento da pena na segunda fase de seu cálculo. Além disso, o STJ já decidiu que a reincidência, por si só, não afasta o "tráfico privilegiado": "A ínfima quantidade da droga apreendida não justifica o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo perfeitamente cabível a sua aplicação em patamar intermediário (1/2), diante da reincidência" (HC 660.930/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021). Dessa forma, nada impede que seja reduzida a pena do réu, ainda que não seja no patamar máximo. Portanto, seja pela desproporcionalidade da medida no caso concreto, seja pela impossibilidade de se utilizar a mesma circunstância para agravar duplamente a situação da pessoa acusada, a Defesa pugna pela aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Por consequência, requer-se a fixação de regime inicial diverso do fechado em favor do réu, mesmo porque a pena final não deve ultrapassar oito anos de reclusão. Por fim, requer-se seja conferido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:
Vistos,

DOUGLAS PAULO DOS ANJOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 11,24 horas, na Rua Mercúrio nº 59, Bairro Jardim Planalto, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, trazia consigo, para fins de tráfico, 3,3g de cocaína na forma de pedra, distribuídos em 21 invólucros, 1,9g de cocaína, distribuídos em 06 "ependorfs" e 19,8g de Cannabiss sativa L., distribuídos em 10 invólucros, substâncias entorpecentes as quais determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que, no dia dos fatos, guardas municipais estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, ocasião em que visualizaram o acusado, o qual, ao notar a aproximação da viatura, tentou se evadir. Em razão disso, abordaram-no e, em revista pessoal, localizaram as drogas acima descritas, pertencentes a ele e que se destinavam à mercancia ilícita, bem como a quantia de R\$87,00, produto do narcotráfico.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 104). Defesa preliminar apresentada às fls. 107/110. Após, a denúncia foi recebida (fls. 118) e o réu foi citado às fls. 147.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade do delito.

A Defesa arguiu ilicitude da ação dos guardas civis. Em caso de condenação por tráfico, requereu o reconhecimento do privilégio.

É o relatório.

Decido.

Afasto a tese defensiva de que houve ilegalidade na ação dos guardas civis e, conseqüentemente, nulidade da prova.

Os guardas civis integram os quadros funcionais do Município, cujo desempenho básico é a defesa do patrimônio público municipal. Como atuação secundária, cabe aos guardas civis a defesa da população local, compreendida a repressão de atos criminosos danosos aos cidadãos, até porque, caso assim não ajam, respondem na forma do artigo 13, §2º, "a", do Código Penal, por omissão imprópria, pois têm o dever de agir, na medida em que a lei obriga o dever de cuidado, proteção e vigilância.

Além disso, a preservação da ordem pública é responsabilidade de todos, sendo conferido aos Órgãos de Segurança o dever legal.

Desta forma, é conferida à Guarda Civil a possibilidade de prender quem estiver em flagrante delito, bem como recolher todos os instrumentos utilizados na prática da infração penal, a fim de que melhor subsidie a apuração dos fatos, nisto incluída a revista pessoal.

Registre-se, ainda, que em 2014 foi sancionada a Lei 13.022/14, que dispõe acerca do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Referido diploma legal institui normas gerais para as Guardas Municipais, disciplinando o artigo 144, §8º, da Constituição Federal.

A Lei 13.022/14 constitui norma geral, aplicável a todas as leis municipais que tratem sobre suas respectivas guardas, posto que cada Município deve editar a sua própria lei, adequando-se às disposições do Estatuto Geral das Guardas Municipais. A importância dessa Lei encontra-se no fato de que amplia a restrita interpretação que se havia do artigo 144, §8º, da Constituição Federal.

De fato, dispõe esta norma constitucional que "os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei". A interpretação restritiva encontra-se no fato de que as Guardas Municipais sempre tiveram um papel relacionado com a proteção do patrimônio municipal. A Lei 13.022/14 amplia a interpretação, estabelecendo que as Guardas Municipais podem colaborar com os demais Órgãos de segurança pública, no caso as Polícias Civil e Militar.

Isso se depreende das competências que a Lei confere às Guardas Municipais. O

artigo 4º atribui a competência geral, qual seja, a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município, conforme já previsto na Constituição Federal. Por outro lado, o artigo 5º adjudica as competências específicas. E é entre as competências específicas que podemos destacar que as Guardas Municipais não estão restritas à proteção do patrimônio municipal, mas também lhes são atribuídas funções de colaboração na apuração penal e defesa da paz social.

Outrossim, não cabe qualquer alegação de inconstitucionalidade da Lei 13.022/14, por ter este diploma conferido poderes às Guardas Municipais de atuarem em prol da segurança pública. Em primeiro lugar, as Guardas Municipais integram o sistema de segurança pública do Estado, razão pela qual se encontram em um dos parágrafos do artigo 144, da Constituição Federal. Em segundo lugar, a atuação das Guardas Municipais é sempre ligada às suas atribuições constitucionais (proteção do patrimônio municipal) ou, quando mais ampla, atuará em colaboração com os demais Órgãos de segurança pública (Polícias Civil ou Militar). Inclusive, é o que dispõe o artigo 5º, IV e parágrafo único, da Lei. Por fim, as Guardas Municipais, quando no exercício da sua competência, deverão obedecer às competências dos Órgãos Federais e Estaduais, prestando o auxílio necessário para a elucidação dos fatos. Pelo que se vê, as Guardas Municipais estão investidas na incumbência de garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de delitos, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência ou, no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.

Ainda que assim não fosse, não haveria a alegada ilegalidade.

Embora a Constituição Federal, em seu artigo 144, § 8º, ao elencar as funções da Guarda Municipal, não cite a atribuição de polícia ostensiva, isto não importa em vedação a que prendam em flagrante suspeitos, bem assim que apreendam bens relacionados ao delito praticado.

Conforme revelou a prova que a seguir será analisada, o réu foi visto em situação suspeita de tráfico e, quando avistou a viatura, evadiu-se e isso permitiu a ação dos guardas civis.

Registre-se que, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante aquele que está cometendo crime, inexistindo óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais. Neste sentido, jurisprudências:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO - Preliminar - Nulidade ante a abordagem ter sido realizada por Guardas Civis Municipais - Não ocorrência - Existência de justa causa para a realização da medida - Agentes que possuíam informação a respeito daquele veículo ser utilizado para abastecer o tráfico - Possibilidade para averiguação - Delito permanente, de modo que o acusado se encontrava em situação de flagrante delito - Mérito - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas - Fala dos agentes firmes e coerentes - Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública - Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu - Quadro Probatório seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório - Pena e regime que não comportam alteração - Preliminar rejeitada e recurso desprovido". (TJSP. Apelação Criminal 1500184-29.2020.8.26.0567. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR EDISON BRANDÃO j. 05/10/2020) g.n.

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EFETUADO POR GUARDA MUNICIPAL. VALIDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, é possível que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, o agente municipal proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. 2. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. Precedentes. 3. A prisão preventiva é

compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 4. O Juiz de primeira instância mencionou fato concreto que evidencia o periculum libertatis, ao salientar que "foi efetuada a apreensão de uma balança de precisão, 01 tijolo de maconha e mais 144 (cento e quarenta e quatro) porções da mesma droga, acondicionadas em pequenas porções, próprias para venda", nos termos do acórdão a quantidade do entorpecente totalizou 782,9g. Ficou registrado, ainda, que o síndico do condomínio, relatou que "Charles Rogério Mendes Júnior é o responsável pela sala de energia, bem como detentor das chaves do local onde foram encontrados os entorpecentes" 5. A adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade das condutas perpetradas (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do acusado. 6. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8º, § 1º, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, "em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal", ou caso "as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias". 7. No caso, não há comprovação de que o paciente integra o grupo de risco ou que não esteja inserido em estabelecimento prisional superlotado. 8. Ordem denegada." (STJ - HC 583.610/SP. SEXTA TURMA. Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - j. 04/08/2020) g.n.

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 20/02/2020; HC 180.365-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 27.03.2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe de 03/06/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 03/04/2018. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexiste óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 3. Como é de conhecimento, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, constataram a presença da materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, de modo que a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 5. Nos termos do verbete n. 630 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso

próprio". Assim, na hipótese, não há se falar em incidência da referida atenuante. 6. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 586.612/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA j. 25/08/2020) - g.n.

Afastada, dessa forma, a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito. A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) Boletim de ocorrência de fls. 05/06;
- 2) Auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e fotografia de fls. 16 e
- 3) Laudo de constatação de fls. 09/14 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 95/97, com resultado positivo para cocaína e tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 04), o réu confessou o crime. Declarou que tinha antecedentes criminais e que foi abordado por guardas municipais e que estava traficando na rua Zulmira Ferreira do Valé, pela cidade de Piracicaba.

Interrogado em juízo, novamente confessou o tráfico, dizendo que portava as porções de drogas descritas na denúncia para fins de comércio. Alegou que fazia isso em razão de dificuldades financeiras. Declarou-se arrependido.

A confissão foi corroborada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 02) e em juízo (gravação), o guarda civil César Eduardo Bottene declarou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina pelo bairro Cantagalo quando avistaram o réu no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, carregando uma sacola nas mãos, descendo uns degraus rumo a uma rua sem saída. Quando se deparou com a viatura, ele apresentou nervosismo e, assim, resolveram abordá-lo. Ao se aproximarem, ele imediatamente levantou as mãos e disse "perdi". Na sacola que ele trazia em suas mãos foram encontrados 21 unidades de "crack", 06 unidades de cocaína, 10 unidades de maconha e a quantia de R\$ 87,30 em notas diversas. O confessou que estava traficando na área verde do bairro Canta Galo porque estava precisando de dinheiro para se sustentar e manter a família.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 03) e em juízo (gravação) pelo guarda civil Paulo Cesar Cavalcante.

Anoto que os relatos dos guardas civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a uma pessoa a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos

agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 3,3g de "crack", distribuídos em 21 invólucros, 1,9g de cocaína, distribuídos em 06 "ependorfs" e 19,8g de maconha, distribuídos em 10 invólucros, substâncias estas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De fato, os guardas municipais avistaram o réu em atitude suspeita no local dos fatos carregando a sacola com as drogas e apresentando nervosismo ao notar a presença da viatura.

Os entorpecentes foram apreendidos na posse dele. O réu ainda possuía dinheiro junto com as drogas.

Ele confessou o crime não só perante a Autoridade Policial, mas também em juízo, admitindo, outrossim, que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito e que o dinheiro era produto das vendas.

O destino mercantil dos entorpecentes ficou evidenciado não só pelas circunstâncias da abordagem e a confissão do réu, mas também em razão da diversidade de drogas, incompatível com a situação de mero usuário, bem como pelo fato de estarem embalados em porções individuais, como geralmente são comercializadas.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis, razão

pela qual fixo a pena-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Reconheço a agravante da reincidência (condenação definitiva no processo criminal nº 640-30.2015, fls. 33 e nº 5372-76.2016, fls. 33/34) e, por outro lado, a atenuante da confissão da autoria do crime. Como ambas as circunstâncias são consideradas preponderantes, deixo de aumentar ou diminuir as penas na segunda fase.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de penas.

Registro que a reincidência impede a aplicação do redutor do parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06 e impõe a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis (estes também incabíveis em razão da quantidade de pena aplicada), pois indica que o réu vem reiterando na prática de crimes.

Acrescente-se a isso as graves consequências do delito de tráfico, que fomenta a prática de vários outros crimes, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que dificilmente conseguem se livrar do vício.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu sentisse as consequências de seu grave ato.

Há várias decisões de nossos Tribunais no sentido de que é possível a eleição do regime fechado, sem substituição por restritivas de direitos, no crime de tráfico de drogas se a natureza, a reincidência e as circunstâncias concretas do crime indicarem tratar-se de agente de maior periculosidade.

Confira-se julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Revisão criminal - Tráfico de drogas e Trazer arma consigo sem licença - Art. 33, caput, da lei 11.343/06 e art. 19 da Lei de Contravenções penais - Absolvição quanto ao crime de tráfico - Ausência de decisão contrária à prova dos autos - Robusto conjunto probatório - Narrativas dos policiais militares são seguras, coerentes e indicam o encontro de drogas com o peticionário - Tais depoimentos não devem ser desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa a ele - Ademais, a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos - Em sede de revisão criminal, não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao reconhecimento da culpabilidade do acusado, mas tão somente verificar se a condenação foi contrária à evidência dos autos. E esse não é o caso dos autos, pois a prova colhida no decorrer da instrução resultou suficiente para a prolação de decreto condenatório - Reincidência devidamente demonstrada, o que torna incogitável aplicar o redutor - Regime fechado inalterado, tendo em vista a presença da recidiva do acusado - Pena maior de quatro anos, o que impossibilita a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos - Pedido indeferido." (TJSP - Revisão Criminal 2031611-39.2020.8.26.0000. 4º Grupo de Direito Criminal. Relator (a): Freitas Filho - j. 29/09/2020) - g.n.

Registro que o reconhecimento da reincidência para fins de impedir a concessão de benefícios ao acusado e apená-lo de forma mais grave não fere a coisa julgada, nem constitui "bis in idem", pois não se trata de punir o agente duas vezes pelo mesmo fato.

Como bem ensina Guilherme de Souza Nucci, essa ideia "peca pela simplicidade. O sistema de fixação de penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF)" (CPComentado - RT, 13ª ed., pag. 464).

Ao se reconhecer a reincidência e aumentar a pena do crime em razão dessa agravante ou deixar de aplicar ao réu alguma benesse, o Estado nada mais faz do que punir com maior rigor o agente que, tonando a delinquir, desafia a ordem pública e as leis vigentes, demonstrando, no dizer do professor Nucci, "persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade. Destarte, sofre uma punição mais severa" (obra citada, pag. 464).

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes

e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico. APELAÇÃO CRIMINAL - PENA E REGIME PRISIONAL - Pena fixada com critério e corretamente - Reincidência do réu que inviabiliza a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas - Bis in idem não caracterizado, pois o aumento na segunda etapa e a impossibilidade de aplicação do privilégio na terceira fase são efeitos distintos decorrentes do mesmo instituto - Inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, por força do disposto nos artigos 44, incisos I e II, e 77, caput, e inciso I, ambos do CP - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso desprovido." (TJSP - Apelação 0003941-43.2015.8.26.0127 - 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Nelson Fonseca Junior - j. 14/09/2017) -g.n.

Pelos mesmos motivos, fica vedado o direito do réu apelar em liberdade, pois necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Registro que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o réu está preso há apenas três meses e vinte e dois dias, não tendo, ainda, preenchido o requisito objeto para progressão de regime.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu DOUGLAS PAULO DOS ANJOS SANTOS a cumprir cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado nos autos que a quantia apreendida em poder do acusado é decorrente do tráfico, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Diante da reincidência e considerando a maior gravidade do crime em comento, considerado hediondo, verifica-se maior gravidade da conduta e real possibilidade de reiteração criminosa. Assim, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual fica mantida. Recomende-se o réu na prisão em que ele se encontra recolhido, servindo-se a presente de ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo Representante do MP, RÉU e DEFESA foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se o necessário. Oportunamente, archive-se.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.